Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 7ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810373

Processo nº 0061738-49.2023.8.17.2001

AUTOR(A): LIGIA TORRES GALINDO

RÉU: UNIMED-RIO

SENTENÇA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO INDIVIDUAL DE PLANO DE SAÚDE ANTIGO E NÃO ADAPTADO. INAPLICAÇÃO DA LEI Nº 9.656/1998. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA E DAS REGRAS DA LEI Nº 8.0178/1990. OCTAGENÁRIA PORTADORA DE ANEMIA FERROPRIVA GRAVE. REQUISIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO NORIPURUM POR MEIO ENDOVENOSO. USO HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. ROL DE PROCECIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE QUE É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. DANO MORAL EVIDENCIADO. PROCEDÊNCIA.

- Preliminar de falta de interesse de agir. Expressa recusa para cobertura aliada à formalização de defesa de mérito. Provimento jurisdicional que se mostra imprescindível para a defesa do bem de vida. Rejeitada.

- Impugnação à gratuidade da Justiça. Presunção de veracidade da condição de miserabilidade jurídica que não foi elidida. Afastada.

- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Súmula 608 do STJ.

- Contrato individual antigo e não adaptado. Afastamento das regras de cobertura previstas na Lei nº 9.656/1998. Tema 123 do STF.

- Mesmo nos contratos anteriores à Lei 9.656/98 revela-se abusiva a negativa de cobertura dos custos de medicamento quando este for indispensável para o sucesso do tratamento da paciente, mercê do arcabouço principiológico extraído do CDC e da Constituição: dignidade da pessoa humana, proteção à vida e à saúde, boa-fé objetiva.

- Em que pese antiga divergência interna no Superior Tribunal de Justiça, sempre perfilhei o entendimento que define o "*caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, na linha da*

jurisprudência pacífica desta TURMA, firmada com base na função social do contrato de plano de saúde" (AgInt no REsp 1911407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

- A exemplificatividade do RPES da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ademais, acha-se recentemente consolidada no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

- A operadora plano de saúde pode estabelecer quais as doenças serão cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser alcançado pelo paciente, nos moldes requisitados pelo médico assistente. Contrato que preconiza expressamente a cobertura de doenças hematológicas.

- Afigura-se nitidamente abusiva a exclusão genérica de custeio de medicamento de uso hospitalar ou ambulatorial, ainda que o contrato não se submeta à Lei de Saúde Suplementar. Inteligência do art. 51, IV e IX, CDC.

- A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde rende ensejo à indenização por dano moral. Súmula 35 do TJPE. Quantia fixada em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

- Pedidos que se julgam procedentes.

Vistos etc.

Cogita-se, na espécie, de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer manejada por **LÍGIA TORRES GALINDO** em face de **UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA,** ambas devidamente qualificadas**.**

Alega a idosa proponente (84 anos) em suma que, na condição de cliente da ré com suas obrigações em dia, viu-se acometida de diversas doenças, dentre elas a ANEMIA FERROPRIVA, e que, em conformidade com requisição médica, dada a sua debilitação e falta de resposta ao tratamento oral, necessita de iniciar tratamento injetável com o medicamento Noripurum 2 ampolas + SF 200ml mediante aplicação endovenosa uma vez por semana, de 8/8 dIas, num total de 4 aplicações.

Em continuidade, relata que a operadora demandada negou o tratamento, ao argumento de que o contrato de assistência médica do qual a promovente é beneficiária não possuía cobertura para tal procedimento.

Face a esse estado de coisas, invocando a legislação consumerista, veio a Juízo pleitear a condenação da parte ré na cobertura do tratamento medicamentoso requisitado, inclusive em sede de tutela de urgência de caráter antecipatório, além de indenização por danos morais que estima em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou instrumento procuratório, documentação instrutória e requereu gratuidade da Justiça.

Foi proferida **decisão** sob ID nº 134788061 deferindo liminarmente a tutela, concedendo a mercê do art. 98, CPC, e determinando a citação.

Regularmente citada, a operadora UNIMED RIO apresentou **contestação** sob ID nº 139706282 arguindo preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão de resistida e impugnando o pedido de assistência judiciária.

No mérito, aduz que o contrato mantido entre os contendores é antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/1998, de modo que as coberturas devem ser aquelas estipuladas na avença, salientando que a cláusula 11.1, item XVIII, das condições gerais, expressamente exclui o custeio de medicamentos fora do ambiente de internação. Em continuidade, suscita que o tratamento é de uso domiciliar e tampouco constaria do rol de eventos e procedimentos em saúde da agência setorial, arrematando com tese de que a limitação dos riscos seria plenamente válida, como exercício regular de direito, infirmando a configuração de quaisquer danos morais. Ao enfim, pugna pela improcedência dos pedidos vestibulares.

A parte autora apresentou **réplica** sob ID nº 143433544 rebatendo as teses de defesa e reprisando os requerimentos atriais.

Seguiu-se despacho de ID nº 143876976, indagando dos contendores sobre interesse na autocomposição ou na dilação probatória, bem como invertendo o ônus da prova em favor da parte autora.

Em resposta, ambos os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (petições de ID nº 145662426 e 148233347).

Houve alegações finais reiterativas.

Relatados, PRONUNCIO-ME.

De proêmio, cumpre rejeitar a insurgência quanto à gratuidade da Justiça outorgada à idosa promovente.

A uma, porque a declaração de pobreza goza de presunção (ainda que relativa) de veracidade (art. 99, §3º, CPC/2015), de modo que apenas com robusta prova em contrário é que tal ilação poderia ser obliterada, o que não ocorreu no caso concreto. A duas, porque as informações prestadas na peça de ingresso reforçam a presunção de miserabilidade jurídica. A três, e por último, porque o só-fato de estar a parte sendo representada em Juízo por patrono particular não elide nem vulnera o fato de que não está apta a arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da familiar (art. 99, §4º, CPC/2015).

Ainda neste viés, rejeito de logo a prefacial de falta de interesse de agir, a uma, porque a parte ré ignorou (ou tentou engabelar) o fato de que houve recusa expressa para o tratamento medicamento (ID nº 134731884) e, a duas, porque, ainda que assim não fosse, o só-fato de haver defesa direta de mérito já torna necessária e adequada a intervenção judicial no caso concreto.

Estando o feito em ordem, adentro de pronto ao *meritum causae*.

Dentro desse contexto, inicialmente, assento que ao caso concreto são aplicadas as regras de proteção ao consumidor, em conformidade com a **Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça**.

Para além disso, tenho por induvidoso que a promovente ostenta legitimidade para exercer o *jus postulandi*, eis que evidenciada a sua condição de beneficiária de plano de saúde com suas obrigações em dia (ID nº 134731120 e 134731130).

No que concerne com a incidência ou não da Lei nº 9.656/1998, destaco que, em efetivo, a espécie cuida de contrato anterior e não adaptado/regulamentado, de modo que a mencionada norma não se aplica. Não é outra a conclusão extraída do **Tema 123 do Supremo Tribunal Federal**, *verbis*:

> "As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados".
> (Recurso Extraordinário nº 948634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020)

Em que pese isso, pela narrativa da peça vestibular, não é difícil concluir que a eventual progressão do estágio da doença provocará desvio expressivo e quiçá irremediável na saúde da **octogenária promovente**, influindo consideravelmente na evolução socialmente maligna da enfermidade.

Quero com isso dizer que, independentemente da irretroatividade legal defendida, é possível apreciar a negativa de cobertura à luz do CDC e de toda a estrutura principiológica trazida pela Constituição Federal. Isso porque o art. 4°, III, e 7° do CDC permitem a interpretação harmônica dos interesses dos consumidores e fornecedores.

Ao consagrar os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da vulnerabilidade, a Lei nº 8.078/1990 trouxe importantes inovações no âmbito das relações contratuais, permitindo o restabelecimento de um equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor (uma vez dispor esse último de melhores condições técnicas, econômicas e intelectuais para perseguir seus interesses).

Assim, **apesar da não incidência da Lei 9.656/98, é possível apreciar a obrigatoriedade de cobertura com base no arcabouço principiológico do Código de Defesa do Consumidor e no princípio da Dignidade da Pessoa Humana acoplado ao art. 1° da Constituição Federal.**

Há de se destacar que, em conformidade com o regramento estampado na legislação consumerista, o direito lastreado na boa fé ostenta especial relevância em prol do consumidor, mormente quando se cuida de situação de risco no que concerne à higidez física dos pacientes (arts. 5º e 196 da Constituição Federal) situação essa que se acha patenteada no teor do documento médico que sinaliza para a necessidade de submeter a suplicante, de idade avançadíssima e vítima anemia ferropriva, à referida medicação.

Com efeito, cabível assentar que a perpetuação da doença sem o devido tratamento ensejaria dano irreparável, o qual exige premente e pronta alberga judicial.

Para além disso, cumpre assentar que o CDC é norma de ordem pública (art. 5º, XXXII, da CF), sendo certo que o plano de assistência médico-hospitalar é contrato de trato sucessivo, que se renova a cada mensalidade.

A Constituição Federal assim prescreve:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

É que entende este Juízo, em consonância com a moderna jurisprudência, que a circunspeção e seriedade da moléstia, passível de cobertura contratual como no caso, bem como o prazo para o respectivo tratamento, não podem ser aferidos pela análise administrativa da empresa seguradora. Antes, é ilação a que apenas o médico assistente pode chegar, mediante a anamnese da situação em concreto.

Neste diapasão, denota-se claramente que a parte autora está a clamar, primacialmente, pelo respeito à saúde e à vida social digna, batendo por isso às portas do Judiciário, que ao longo dos anos vem se revelando o último refúgio e recurso dos aflitos e necessitados.

Ademais, consoante se infere da documentação acostada aos autos, afigura-se igualmente induvidoso que está a reclamante/consumidora a pleitear cobertura para atendimento que objetiva sua **reabilitação hematológica**, em face da anemia ferropriva (laudo médico de ID nº 134731882).

Destaque, por absolutamente oportuno, que existe expressa previsão contratual acerca da cobertura do tratamento de hematologia, consoante se dessume na Cláusula 5.1 das Condições Gerais acostadas ao ID nº 139706306.

Para além disso, **o laudo médico bem descreve que a ministração injetável deve ser endovenosa, não se tratando, portanto, de medicamento de uso meramente domiciliar**, como tenta incutir a parte reclamada.

Mesmo que fosse de uso domiciliar, decerto, afigura-se abusiva, nos termos do art. 51, CDC, a cláusula excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que ministrado fora do ambiente nosocomial.

Em prol deste pensar, vide:

> CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. USO DOMICILIAR. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O entendimento dominante nesta Corte é de que é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e independentemente de figurar no rol da ANS, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.949.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1064435/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)

A presente ação visa, assim, à responsabilização da operadora promovida pelo custeamento do medicamento NORIPURUM, que vem se apresentando como firme resposta para o tratamento da anemia ferropriva, tudo o que, conforme solicitação e declarações repousantes aos autos, afigura-se de todo mister e foi, portanto, requisitado para a precaução de maiores lesionamentos a sua integridade visual.

Periclitado o estado de saúde da paciente portadora da moléstia, remansa a evolução do quadro clínico gravoso descrito na peça vestibular, razão pela qual se afigura imperativo o aprofundamento de seu tratamento com vista ao acautelamento dos perversos danos experimentados, como defesa dos direitos fundamentais de proteção da vida e da incolumidade física e psíquica (art. 196 e segs., da CF de 1988), sendo certo que, há muito, a jurisprudência vem entendendo por abusiva a extirpação arbitrária ou a protelação de exames ou tratamentos nos dispositivos contratuais deste jaez.

Acrescente-se que, *in casu*, nada obstante o afastamento da Lei nº 9.656, de 03.06.1998, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que assegura, com lastro constitucional, a preferência do direito à vida e à saúde em favor do hipossuficiente.

Dessa forma, cabe ao magistrado, quando vislumbrados os pressupostos específicos, fazer preponderar o bem jurídico da vida que, a toda evidência, sobrepõe-se aos interesses imediatamente econômicos da parte demandada.

Registre-se, por oportuno, que cabe ao profissional da saúde indicar o tratamento a ser experimentado pela paciente, e não ao plano de saúde. Vale dizer: o médico e não o plano de saúde é responsável pela orientação terapêutica e que entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que "***o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura***" (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).

Vale salientar que o medicamento NORIPURUM (Sacarato de Óxido Férrico) encontra-se desde o ano de 2000 registrado na ANVISA (Registro nº 106390099/Autorização nº 1.00.639-8).

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ entende que "***as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. Mas, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário***" (STJ - AgInt no REsp: 1830041 SP 2019/0229252-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

Saliento ainda que **mesmo nos contratos anteriores à Lei 9.656/98 revela-se abusiva a negativa de cobertura dos custos de medicamento quando este for indispensável para o sucesso do tratamento da paciente**, como é o caso nos autos.

Em efeito, a negativa do plano de saúde a cobertura do NORIPURUM não se justifica porque, de acordo com o médico assistente, tal tratamento é o mais adequado ao quadro clínico apresentado. Em outras palavras, se o tratamento à base do medicamento está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, e o mal que acomete a autora, no caso, degeneração macular tem cobertura, cabe unicamente ao médico especialista indicar qual tratamento é a melhor opção para a paciente para que alcance a cura ou melhoria no seu estado clínico.

Em prol deste pensar, vide:

> EMENTA: Apelação cível. Plano de saúde. Paciente diagnosticado com anemia severa decorrente de sangramento. Prescrição de tratamento com uso do medicamento Ferrinject. Dever de cobertura. Danos morais configurados. Valor indenizatório. Manutenção. Recurso não provido por unanimidade.
> 1) Cabe aos profissionais de saúde avaliar a situação de saúde de seus pacientes e, com base nisso, indicar-lhes o melhor tratamento.
> 2) Cabe à Seguradora oferecer aos seus segurados a opção de adaptação dos contratos firmados anteriormente à vigência da Lei 9.656/98. Por conseguinte, somente é possível afastar a aplicação da referida legislação quando o consumidor houver comprovadamente optado por não adaptar o seu contrato.
> **3) Os laudos médicos anexados aos autos justificaram a necessidade do medicamento a ser ministrado em ambiente hospitalar, diante da ausência de controle satisfatório do quadro clínico do paciente, apesar de ele já ter se submetido a tratamento com reposição endovenosa de ferro.**
> 4) Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para a cura de cada uma delas.
> 5) O Rol da ANS não é taxativo, servindo como mera referência de cobertura para as operadoras de planos privados, conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Justiça.
> 6) Cabível majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC.
> 7) Recurso não provido por unanimidade.

(TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0045294-09.2021.8.17.2001, Rel. FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, julgado em 15/03/2023, DJe)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ANEMIA FERROPRIVA. URGÊNCIA DO TRATAMENTO COM MEDICAMENTO VIA VENOSA EM HOSPITAL OU AMBULATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
- Paciente portadora de anemia ferropriva, com 38 anos de idade, planos de engravidar e sintomas como astenia, tontura e perda de cabelos; hipótese em que se vislumbra a urgência necessária ao provimento recursal, diante do prejuízo à rotina da enferma e à concretização da gestação.
- Recurso provido, para determinar que a Agravada autorize, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), a realização da terapia prescrita pela médica responsável à Agravante.
(TJPE, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0008375-15.2017.8.17.9000, Rel. FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (Processos Vinculados - 2ª CC), julgado em 24/11/2017, DJe)

Ainda que não seja exatamente o caso - pois o Rol da ANS é dirigido aos contratos novos ou adaptados à Lei nº 9.656 - certo é que o princípio constitucional do direito à vida e à saúde e do dever das seguradoras, em substituição ao Estado, oferecer sua escorreita prestação não devem ser considerados em planos inferiores aos dos casuísmos normativos ou contratuais, nem à burocracia das firmas contraentes, revelando-se direito líquido e certo da parte acionante, amparável na via ordinária, a reparação pelas expensas com a realização da cirurgia indicada, em situação de urgência ou emergência.

Desse modo, julgo ser ilegal a recusa à concessão da cobertura, vez que apesar da ANS, no seu Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não ter incluído o NORIPURUM como de cobertura obrigatória, cuido tratar-se de listagem meramente exemplificativa e de cobertura mínima, não devendo ser considerada taxativa a excluir a responsabilidade de fornecimento do tratamento, sendo a negativa incompatível com os princípios da equidade e boa-fé.

O tema se encontrava divergente entre a Quarta e a Terceira Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Desde então, sempre perfilhei o entendimento da Terceira Turma, a qual, no contexto, transcrevo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL (CPC/2015). DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PALBOCICLIBE (IBRANCE). RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUATRAMENTO NA DIRETRIZ DE COBERTURA DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES DA ANS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do medicamento antineoplásico PALBOCICLIBE (IBRANCE) a paciente acometida de câncer de mama metastático, tendo havido recusa da operadora sob o fundamento de ausência de enquadramento do caso nas diretrizes de utilização previstas no rol de procedimentos mínimos da ANS.
2. Caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, na linha da jurisprudência pacífica desta TURMA, firmada com base na função social do contrato de plano de saúde.
3. Caso concreto em que a paciente se encontra acometida de doença oncológica grave e progressiva, de modo que a recusa genérica de cobertura (sem instauração de junta médica nos termos da RN ANS 424/2017) deixou a paciente padecendo à própria sorte no tratamento da doença, desatendendo assim à função social do contrato, segundo a linha de entendimento desta TURMA.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1911407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO. ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL.
REEXAME DE PROVAS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.
3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
4. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Ainda neste viés, a Corte de Uniformização Infraconstitucional também se define "***no sentido de que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, cabendo apenas ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente***". (AgInt no REsp 1870789/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Ademais, também recentemente, caiu por terra a discussão existente sobre a taxatividade do Rol da ANS e a obrigatoriedade de custeio de tratamentos não previstos na lista ofertada pela Agência Reguladora.

É que a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656, de 1998, estabelece que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (RPES), atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Desta feita, acha-se definitivamente profligado o entendimento pelo "rol taxativo" para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos ainda que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Tratamentos fora dessa lista deverão ser aceitos, desde que cumpram uma das condicionantes: ter eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ter recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou ter recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. Vejamos:

Art. 10. (...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

É bem esse o caso dos autos.

Nos contratos onde existem cláusulas que venham prejudicar a parte mais fraca da relação de consumo, em detrimento das máximas da boa-fé objetiva e da confiança, há que se as considerar abusivas, devendo ser reconhecidas judicialmente por meio de ação ou reconvenção, de exceção ou por ato *ex officio* do Juiz.

O artigo 51, incisos IV e IX do CDC, dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)
IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a eqüidade; (...)
IX deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor.

Inobstante tal realidade, a empresa demandada persistiu em negar a cobertura do tratamento integral, sugerindo reembolsá-lo apenas parcialmente, nada obstante não ostente estabelecimento e profissionais vinculados capacitados para tanto, olvidando assim as garantias constitucionais e da legislação consumerista.

Sopesando, em conclusão todos os argumentos expendidos, tenho que se afeiçoa induvidoso que o pleito formulado pela autora merece acolhimento.

Por outro lado, a exclusão do dever de cobertura por cláusula contratual ou instrumentos de convênio firmados com terceiros, malgrado descrita em supostos estudos atuariais, constitui indisfarçável e frontal violação do regramento estampado na legislação protetiva do hipossuficiente porquanto soa implausível, eivada a não mais poder de abusividade e, *pour cète cause*, nula de pleno direito, o que fica aqui expressamente reconhecido e declarado, na forma do art. 52 inc. IV da Lei 8.078/1990, e art. 168 par. único do nCC.

Não se pode olvidar que, imbuída da mais intangível boa-fé, acedeu a parte autora às letras previamente anotadas pela seguradora na esperança de ver resguardados seus direitos e liberdades constitucionais, no que dizem com sua dignidade, vida e incolumidade física e mental.

Decerto, perseguir valores indevidos ou negar cobertura securitária quando se evidencia negligência ou mesmo cavilosidade na arguição do dispositivo da avença concernente à imprevisão no ajuste é clausular a iniquidade e a abusividade, o que, face à ordem normativa consumerista, não pode prosperar.

Por isso, entendo que a mencionada negativa, ainda que lastreada em anteparo contratual (Cláusula 11.1, item XVIII), não merece guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, no caso posto a lume, anote-se que o tratamento é tido como fundamental para salvaguardar a higidez física da paciente e deve ser realizado mediante rigoroso acompanhamento médico em ambiente hospitalar/ambulatorial.

Sopesando, pois, os interesses jurídicos em conflito - de um lado, o direito à vida e à integridade física da querelante, e, de outro, os interesses econômicos da seguradora ré - é mister dar primazia ao direito à vida, postulado fundamental inscrito no art. 5º da Constituição.

Quanto ao pedido indenizatório, exsurge nítido que merece prosperar nos termos os artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil.

O dano e a relação de causalidade estão presentes não só pela negativa de vigência do contrato, mas pelo sentido de perda em relação à reparação da saúde em momento delicado da parte autora, objetivo primordial do procedimento médico irregularmente vetado.

Nesse diapasão, vejo que a prática intentada pela ré infringe o princípio constitucional da solidariedade e contraria os arts 4º e 6º, I, CDC, no que atine à proteção à vida e à saúde, bem assim o art. 14, §1º, pelo defeito na prestação do serviço por não o fornecer da maneira esperada pelo consumidor de boa-fé.

Respeitante ao pedido alusivo aos danos morais, permite-se este Juízo deixar assentada breve conceituação pela qual "*danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico*" (SILVA, Wilson de Melo da. **O Dano Moral e sua Reparação**, Rio, 1995, n° 01).

Encampando esta linha de pensamento, confira-se a **Súmula 35 do TJPE**: "*a negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral*".

Por certo, infligir à paciente - profundamente debilitado pela grave moléstia que lhe acometeu e pelo decurso avançado da idade - o ônus de vir a Juízo buscar a efetivação das suas prerrogativas, em detrimento da paulatina dor e sofrimento que se acha experimentando, significa vulnerar-lhe com absurda iniquidade a aprazia e o bem-estar, carecendo da pronta compensação financeira.

Por suposto, "*embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada*" (STJ - AgRg no REsp 1.328.978/RS - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - Julg. 13.11.2012 - DJe 20.11.2012)

Calha reforçar que o lesionamento, na espécie, não depende de prova de outros prejuízos ao patrimônio material ou físico do postulante, porquanto se caracteriza *in re ipsa*.

Apoiando esta ilação, confira-se:

> EMENTA: Apelação cível. Plano de saúde. Paciente diagnosticado com anemia severa decorrente de sangramento. Prescrição de tratamento com uso do medicamento Ferrinject. Dever de cobertura. Danos morais configurados. Valor indenizatório. Manutenção. Recurso não provido por unanimidade.
> 1) Cabe aos profissionais de saúde avaliar a situação de saúde de seus pacientes e, com base nisso, indicar-lhes o melhor tratamento.
> 2) Cabe à Seguradora oferecer aos seus segurados a opção de adaptação dos contratos firmados anteriormente à vigência da Lei 9.656/98. Por conseguinte, somente é possível afastar a aplicação da referida legislação quando o consumidor houver comprovadamente optado por não adaptar o seu contrato.
> 3) Os laudos médicos anexados aos autos justificaram a necessidade do medicamento a ser ministrado em ambiente hospitalar, diante da ausência de controle satisfatório do quadro clínico do paciente, apesar de ele já ter se submetido a tratamento com reposição endovenosa de ferro.
> 4) Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para a cura de cada uma delas.
> 5) O Rol da ANS não é taxativo, servindo como mera referência de cobertura para as operadoras de planos privados, conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Justiça.
> 6) Cabível majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC.
> 7) Recurso não provido por unanimidade.
> (TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0045294-09.2021.8.17.2001, Rel. FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, julgado em 15/03/2023, DJe)

Em conclusão, tenho ser indevida a recusa da parte ré em cobrir todas as despesas com o tratamento médico-hospitalar do paciente nos termos solicitado pelo médico assistente, devendo suportar os custos com a cobertura devida em relação ao contrato celebrado entre as partes, por abusiva eventual cláusula de restrição, além da indenização por dano moral, este arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando a extensão do dano suportado pela autora e as condições pessoais das partes, mercê dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assento, por fim, que "*na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca*" (**Súmula 326 do STJ**), entendimento este que continua em vigor mesmo após o novo Código de Processo Civil (REsp 1.837.386)

Isto posto e por tudo que restou provado nos autos, tenho por imperativo julgar **PROCEDENTES** os pedidos que se acham contemplados na presente ação ordinária para, reconhecendo a abusividade da recusa, confirmar a liminar e condenar a operadora UNIMED RIO na obrigação de fazer consistente na cobertura do tratamento medicamentoso requerido na inicial, a saber: Noripurum 2 ampolas + SF 200ml mediante aplicação endovenosa uma vez por semana, de 8/8 dias, num total de 4 aplicações, incluindo todos os materiais, artefatos, utensílios e equipamentos imprescindíveis ao sucesso do tratamento, em exata conformidade com a requisição do médico assistente, no prazo e sob as penas já cominadas no *decisum* liminar.

Fica de logo ciente a parte autora que a eventual cobrança de astreintes por alegado descumprimento deverá ser precedida de serena e robusta comprovação do atraso no fornecimento da medicação, sob pena de configuração da litigância temerária (art. 80, II, c/c art. 81, CPC).

Imputo ainda a obrigação de indenizar a parte postulante, em aspecto compensatório pelos sofrimentos e danos extrapatrimoniais que valoro no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a repercussão e reprovabilidade do fato, bem assim a condição socioeconômica das partes litigantes (art. 944, nCC), quantia a ser monetariamente corrigida pela tabela ENCOGE desde este arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação (art. 405, nCC).

Por fim, constatada a hipótese do art. 487, I, do Estatuto de Ritos, extingo o feito por sentença com incursão meritória, imputando à parte ré o ônus da sucumbência, representado pelas custas processuais em aberto, além de honorários advocatícios ora fixados em 15% do valor total da condenação pecuniária, forte no art. 82, §2º, e art. 85, §2º, CPC/2015.

Independentemente de nova intimação, a parte ré deverá comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais após quinze (15) dias úteis do trânsito em julgado, sob pena de que se oficie ao Comitê Gestor de Arrecadação do TJPE (ou quem lhe faça as vezes) para adoção das providências de cobrança cabíveis, incluindo a multa de 20%, na forma dos arts. 22, 27, §3º, da nova Lei de Custas (Lei Estadual nº 17.116/2020).

Intimem-se. Cumpra-se.

Recife-PE, data digitalmente certificada.

Robinson José de Albuquerque Lima

Juiz de Direito Titular

bfsma

Assinado eletronicamente por: ROBINSON JOSE DE ALBUQUERQUE LIMA
07/01/2024 14:52:24
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 157249283

24010714522402800000153601819

IMPRIMIR GERAR PDF